Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
4ª Vara Cível da Comarca de Olinda

Processo nº 0009281-46.2024.8.17.2990

AUTOR(A): JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

# SENTENÇA

Vistos, etc.

**JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA,** qualificado na petição inicial, por advogado constituído pela procuração Id nº 167193806, ajuizou a presente **AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional** em face da **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.,** também qualificada na inicial, alegando o seguinte:

> *O Autor fora submetido ao procedimento de nefrectomia em 2016 em razão de NEOPLASIA RENAL, não tendo necessitado realizar tratamento com terapia medicamentosa adjuvante, permanedendo com a doença controlada.*
>
> *Ocorre que, em março de 2024, fora submetido a novos exames, tendo sido identificada **lesão metastática em região frontal de face (pele) e pulmonares**, conforme evidenciado no laudo do exame Imuno histoquímico **(Doc. 06)**, do laudo da Tomografia Computadorizada de Tórax e Abdome **(Doc. 07)***
>
> *Diante disso, o Autor fora diagnosticado com **NEOPLASIA MALIGNA RENAL (CID10 – C64)**, mais precisamente um **Carcinoma de Células Claras**, **em estágio IV**, **com metástases pulmonares e cutânea**, conforme evidenciado no laudo do exame Imuno histoquímico **(Doc. 06)**, do laudo da Tomografia Computadorizada de Tórax e Abdome **(Doc. 07)**, bem como o laudo médico **(Doc. 08)**:*
>
> *[...]*
>
> *Diante disso, considerando o estágio avançado da doença, o médico oncologista que assiste o paciente, **Dr. Ilan Andrade Pedrosa (CRM/PE 17.624 e RQE 5.040)**, indicou a necessidade de início do tratamento de primeira linha com os medicamentos **Pembrolizumabe 200mg** e **Axitinibe 10mg**, consoante solitação anexa **(Doc. 09)**:*
>
> *[...]*

*Destaca-se que, o referido tratamento foi solicitado, **O MAIS BREVE POSSÍVEL**, tendo em vista tratar-se de **doença rara e grave**, podendo, inclusive, o atraso no acesso ao tratamento acarretar a diminuição da sobrevida livre e global, risco à saúde do paciente e/ou óbito.*

*Nesse toar, frisa-se que, o princípio ativo **Pembrolizumabe** encontra-se devidamente registrado na ANVISA, sob o n° 101710209, tendo como nome comercial o medicamento **Keytruda (Doc. 10)** e o princípio ativo **Axitinibe** também se encontra devidamente registrado na ANVISA sob o n° 121100452 tendo como um dos nomes comercial o medicamento **Inlyta (Doc. 11).***

*Destarte, os medicamentos em questão são expressamente indicados ao caso em comento, pois **trazem expressa indicação em sua bula**, tendo em vista que é um medicamento indicado para o tratamento de pacientes portadores de neoplasia maligna de rins/carcinoma de células renais **(Doc. 12 e 13)**, ou seja, o caso do Impetrante. Vejamos:*

*[...]*

*Diante de todo o exposto, a Parte Demandante, através do médico assistente, requisitou a autorização do tratamento para a Empresa Ré **(Doc. 09)**.*

*Ocorre que, não obstante a Parte Demandante tenha enviado laudo médico acima transcrito para Empresa Ré, **a mesma NEGOU o fornecimento do tratamento com os medicamentos Pembrolizumabe 200mg + Axitinibe 10mg (Doc. 14 e 15)**, que, destaca-se, fora expressamente indicado pelo Médico Oncologista, Dr. Ilan Andrade Pedrosa (CRM/PE 17.624 e RQE 5.040).*

*Destaca-se, ainda, que **a NEGATIVA do tratamento se deu em virtude ausência de cobertura contratual**. Vejamos:*

*[...]*

*Ora, a paciente, que possui **indicação para realização do tratamento pela bula e indicação do médico assistente**, **recebera a injusta negativa de assistência à saúde.***

*Douto Julgador, de plano é perceptível a **abusividade** da conduta da Ré, sendo esta inconcebível face ao ordenamento jurídico pátrio, pois não se pode compreender a atitude da Operadora Ré em NEGAR, sem qualquer pretexto, a autorização para a cobertura das despesas com o tratamento solicitado pelo médico assistente, expondo o Autor a maior risco, inclusive, de vida.*

*Nesse toar, faz-se necessário destacar que o argumento da referida negativa não passa de uma tentativa da Operadora Ré se esquivar da sua obrigação para com a Autora.*

*Ora, primeiramente, convém esclarecer que não é justificável que o plano proceda com negativa de autorização, sob a justificativa de que o contrato não possui cobertura para o tratamento solicitado, haja vista que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, em sede de **AgRg no AREsp 718.634/DF**, in verbis:*

*[...]*

*Desse modo, não é justo que a Demandada, discricionariamente, decida quando e como vai cumprir as disposições contratuais que elaborou e submeteu à adesão do autor, uma vez que sabemos nós que tais contratos de adesão tornam seus aderentes/contratantes "clientes cativos", sendo esta relação mais que duradoura, perduram anos e anos a fio.*

*Além disso, pontua-se que **a negativa dada pela Operadora Ré fora absolutamente evasiva**, uma vez que não cumpre com requisitos previstos no art. 10, caput da Resolução Normativa nº 395/2016 da ANS. Vejamos:*

*[...]*

*Ora, a negativa dada pela Operadora Ré limitou-se a apresentar **motivo vago**, sem proceder sequer com a indicação da cláusula contratual ou o dispositivo legal que a justifique, assim, **violando o dever informacional previsto também no art. 5º, inciso XIV da CF e art. 6, inciso III do CDC**.*

*Em suma, encontra-se o Autor completamente desassistido e desamparado, no que se refre a sua assistência médico-hospitalar, objeto do contrato firmado com o plano de saúde ora Demandado, **estando sujeito à progressão da doença, com consequente piora do seu quadro clínico.***

*[...]*

Em razão dos fatos narrados, o autor requereu o deferimento liminar de uma tutela provisória de urgência, a fim de determinar que que a parte ré "*seja compelida autorizar e custear todas as despesas do tratamento solicitado pelo médico assistente, assim, procedendo com o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe 200mg, IV, a cada 21 dias e Axitinibe 5mg, VO, duas vezes ao dia, contínuo, até evolução da doença, até ulterior decisão judicial*".

No mérito, além do custeio do tratamento, o autor pediu que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Decisão concessiva da tutela de urgência requerida (Id nº 167497009).

A parte demandada foi citada e intimada pessoalmente, por Oficial de Justiça, em 17/04/2024 (Id nº 167689465) e apresentou contestação (Id nº 169677919).

Réplica de Id nº 174944366, ratificando os termos da inicial.

Intimadas as partes sobre produção de outras provas, ambas requereram o julgamento antecipado da lide (Id nº 175991383 e Id nº 175297238).

**Relatados. Decido.**

Cabível o julgamento antecipado, com base no art. 355, I, do CPC, considerando que ambas as partes informaram não ter mais provas a apresentar.

Passando a analisar o mérito da causa, trata-se de ação na qual o autor é paciente oncológico, tendo sido diagnosticado com "neoplasia maligna renal (CID10 – C64), um carcinoma de Células Claras, em estágio IV, com metástases pulmonares e cutânea", razão pela qual pretende que seja a ré compelida a autorizar e dar total cobertura ao tratamento médico descrito na petição inicial, consistente no fornecimento dos medicamentos quimioterápicos Pembrolizumabe e Axitinibe, dizendo que se encontram registrados na ANVISA. Afirmou o autor que ajuizou a presente ação devido à negativa de cobertura por parte da ré, que alegou ausência de cobertura contratual.

Vejo que o autor comprovou a necessidade e a indicação do tratamento por meio de documentos médicos (Id nº 167193815, Id nº 167193818, Id nº 167193819, Id nº 167193822). Juntou prova documental demonstrando o registro dos medicamentos antineoplásicos na ANVISA, bem como informações técnicas (Id nº 167193827, Id nº 167193829, Id nº 167196712, Id nº 167196697). Também fez prova documental da negativa de cobertura (Id nº 167196698, Id nº 167196699), na qual consta o motivo:

[...]

O procedimento que você solicitou não possui cobertura pelo seu plano, conforme disposto em cláusula de EXCLUSÕES DE COBERTURA do seu contrato.

Lembramos que o seu contrato foi celebrado antes da Lei 9.656/98 e não houve solicitação de adaptação nos termos da RN 254 publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

> Por isso, o contrato em questão não é regido pelo Rol de Procedimentos Médicos publicado pela ANS.
>
> [...]

A decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida em 16/04/2024 (Id nº 167497009), devidamente fundamentada na Súmula nº 608 do STJ, no artigo 51, inciso IV e § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e na jurisprudência (TJMG, AI nº 1627961-41.2022.8.13.0000), ressaltando que, **"inobstante não se apliquem as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor (STJ. AgInt no REsp 1954974 SP. Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data do julgamento: 17/11/2021)"**.

Vejamos o dispositivo:

> **[...] DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, DETERMINANDO À RÉ AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A QUE AUTORIZE, NO PRAZO MÁXIMO DE 1 (UM) DIA, CONTADO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO, O TRATAMENTO COM OS FÁRMACOS PEMBROLIZUMABE E AXITINIBE, NA FORMA E QUANTIDADE DESCRITAS NO LAUDO MÉDICO ID Nº 167193819 E NA SOLICITAÇÃO ID Nº 167193822.**

Observo que, na contestação (Id nº 169677919), a parte demandada requer a improcedência do pleito em virtude de o autor possuir plano anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, inexistindo cobertura contratual para o tratamento de câncer. Assim, entende não haver ilícito a ser indenizado, diante do estrito cumprimento das cláusulas contratuais ajustadas, e por não considerá-las abusivas.

A tese de defesa invoca a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 123 com repercussão geral, no *leading case* RE 948634, em sessão virtual de 09/10/2020 a 19/10/2020, em que foi fixada a seguinte tese:

> "As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados".

Deixo registrado que, ao tempo da decisão concessiva de tutela de urgência neste feito, proferida em 16/04/2024, o RE 948634 ainda estava pendente de julgamento de embargos de declaração, o que somente se ultimou em sessão virtual de 10/05/2024 a 17/05/2024, quando o STF rejeitou os embargos por unanimidade, mantendo o acórdão, sobrevindo o trânsito em julgado no dia 18/06/2024. Vejamos o julgado que ficou mantido:

> Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM

RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 948634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/10/2020)

Analisando a prova documental juntada com a contestação, vejo que a ré juntou cópia do contrato celebrado entre as partes, firmado no dia 28/10/1996 (Id nº 169678934). Observo que, de fato, consta na CLÁUSULA 6ª – DAS EXCLUSÕES, expressa exclusão do tratamento de câncer e suas consequências.

Porém, embora não seja aplicável a Lei 9.656/1998 ao caso em tela, por força da tese com repercussão geral fixada pelo STF no RE 948634, transitado em julgado neste ano, é inteiramente aplicável a Lei nº 8.078/90, pois o contrato em questão foi firmado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão concessiva de tutela de urgência, como já dito antes nesta sentença, levou em consideração as regras previstas no artigo 51, inciso IV e § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Tais regras tratam das cláusulas abusivas, que são nulas de pleno direito, por

estabelecerem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, Presumem-se exageradas cláusulas que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.

Assim com base em tais dispositivos, **considero abusiva a Cláusula 6ª do contrato em questão,** ao excluir tratamento das doenças listadas, restringindo direitos ou obrigações que são inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde.

Como se sabe, o espírito do Código de Defesa do Consumidor é tutelar o hipossuficiente na relação de consumo, tratando desigualmente os desiguais, garantido a interpretação das cláusulas contratuais sempre de modo mais benéfico ao aderente (artigo 47), e a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação, assegurando-lhe quando plausível o dano material ou moral, o direito à indenização, independentemente de culpa, em caso de defeitos pertinentes à prestação do serviço (artigo 14). A incidência destas normas ao negócio jurídico que fundamenta o pleito é indiscutível.

Desta forma, demonstrada a relação negocial entre as partes, cabe à ré proporcionar o tratamento necessário em busca da cura do paciente. Portanto, a alegação, por si só, de que o contrato não é adaptado à Lei nº 9.656/1998 é insuficiente para afastar a cobertura do que for indispensável para combater a enfermidade que atingiu a parte autora, pois há que se observar o Código de Defesa do Consumidor.

Note-se que a ré não interpôs recurso de agravo de instrumento para se insurgir contra a decisão Id nº 167497009, e na contestação não impugnou especificadamente os fármacos pretendidos pelo autor.

Ressalto que a ré ainda poderia ter produzido prova (pericial, sobretudo) durante a instrução do presente feito, que pudesse trazer um elemento probatório novo – e técnico – que demonstrasse a contraindicação ou desnecessidade do tratamento em questão. Mas não o fez, visto que disse expressamente na petição Id nº 175991383 que não possuía novas provas a produzir.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que deve ser acolhido.

À luz do art. 5º, V, CF/88, a todos é assegurada indenização por dano material, moral e à imagem em virtude da ocorrência de um ato ilícito.

Já o art. 186 do Código Civil impõe a obrigação de reparar o dano a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Por seu turno, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços quanto a danos causados a consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

De acordo com a Súmula TJPE nº 35: “A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral”.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado a título de indenização por danos morais é razoável e se coaduna com as circunstâncias do caso, levando em conta a situação de hipervulnerabilidade do consumidor em questão, um paciente idoso.

A propósito, deixo registrado que a ré, na contestação, argumentou no sentido da inexistência de dano moral indenizável, mas não impugnou especificadamente o valor pretendido pelo autor.

Com tais considerações, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela de urgência deferida, bem como condenando a ré a pagar indenização em favor do autor, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e com juros nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da citação**.

Condeno a ré, ainda, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios do advogado do autor, no valor correspondente de 20% sobre o valor total atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, do CPC.

Intimem-se.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao TJPE.

Não sendo interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a ré para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Uma vez adotadas todas as providências quanto às custas, e não havendo manifestação da parte interessada quanto ao cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Olinda, data registrada no sistema.

***Eunice Maria Batista Prado***

***Juíza de Direito***

Assinado eletronicamente por: EUNICE MARIA BATISTA PRADO
06/12/2024 20:26:19
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 190210019

24120620261932900000185457935

IMPRIMIR GERAR PDF